

1500073-70.2022.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIQUELME LIMA NOGUEIRA BESERRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA, RIQUELME LIMA NOGUEIRA e Samuel Colmanetti Barbosa, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, valendo-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500073-70.2022.8.26.0633 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 14/09/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500073-70.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIQUELME LIMA NOGUEIRA BESERRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA, RIQUELME LIMA NOGUEIRA e Samuel Colmanetti Barbosa, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incursos nas sanções dos artigos artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c.c. artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06, pela prática dos

fatos delituosos narrados na introital de fls. 01/03, a saber:

“Consta dos autos que, durante pouco mais de 01 (um) mês, período que se encerrou no dia 04 de fevereiro de 2022, neste município de Itanhaém, sobretudo na denominada “Boca do Aeroporto”, bairro Oásis, bem como no bairro Guapurá, SAMUEL COLMANETTI BAROSA, GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA e RIQUELME LIMA NOGUEIRA BESERRA, qualificados às fls. 12/15 e 165/171, associaram-Se entre si e com o adolescente Matheus Nascimento Rocha, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Senival Caviquioli, 72, apartamento 23, bloco I, Guapurá, e na rua Dezesete, nº 253, apartamento 22, Condomínio Andorinha, ambos localizados nesta cidade e comarca de Itanhaém, SAMUEL COLMANETTI BAROSA, GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA e RIQUELME LIMA NOGUEIRA BESERRA, qualificados às fls. 12/15 e 165/171, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e identidade de desígnios entre si e com o adolescente Matheus Nascimento Rocha, guardavam e mantinham em depósito, para fins de comércio ilícito, 1860 (um mil, oitocentos e sessenta) porções de cocaína, com peso líquido de 1.295g; 580 (quinhentos e oitenta) porções de “maconha” (tetrahidrocannabinol), com peso líquido de 1488g; 1 (uma) “pedra de crack” (cocaína petrificada), com peso líquido de 19g, e 20 (vinte) porções de skunk, com peso líquido de 18g, drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo de constatação provisória das drogas de fls. 19/20. Segundo apurado, os denunciados e o adolescente infrator, já em unidade de propósitos criminosos, vieram do município de Ribeirão Preto e instalaram-se em Itanhaém, precisamente na rua Senival Caviquioli, 72, apartamento 23, bloco I, Guapurá, imóvel formalmente alugado em nome do denunciado SAMUEL, tendo então todos se associado com a finalidade de traficar drogas. Para tanto, então, dividiram as tarefas, agindo sobretudo no abastecimento do ponto de venda de entorpecentes conhecido como “Boca do Aeroporto”, bairro Jardim Oásis, acertando-se que ao jovem infrator caberia precipuamente o armazenamento das substâncias ilícitas. Assim, os denunciados e o adolescente eram responsáveis pelo recebimento dos entorpecentes e abastecimento do já referido ponto de venda de drogas, as quais eram armazenadas no apartamento em que o jovem infrator residia, bem como naquele em os demais denunciados passaram a residir e fora alugado pelo denunciado SAMUEL exatamente com essa finalidade. Diante de informações iniciais de que os denunciados armazenavam droga no próprio apartamento, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, diligenciaram na rua Senival Caviquioli, 72, apartº 23, bloco 1, Guapurá, onde apreenderam 17 eppendorfs de cocaína e 15 porções de maconha, ocultas em uma gaveta do armário da cozinha, destinadas ao abastecimento do referido ponto de venda, oportunidade em que também foi apreendida uma anotação com o endereço Rua 17, nº 253, apart. 22, Condomínio Andorinha, imóvel onde os investigadores apreenderam o adolescente infrator em poder de 1843 eppendorffs de cocaína, 565 “trouxas de maconha”, 20 porções de skunk e 01 (uma) pedra de crack, ocultas no dormitório e destinadas ao abastecimento do mesmo ponto de venda.”

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), auto de constatação preliminar de entorpecentes (fls. 22/23), as notas de culpa (fl. 38- Riquelme e fl. 39- Gustavo) e o relatório lavrado pela polícia judiciária (fls. 179/181). Ulteriormente, foi anexado aos autos o laudo toxicológico (fls. 277/280).

Às fls. 89/90 a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu a concessão de liberdade provisória aos acusados Gustavo e Riquelme. O Parquet manifestou-se às fls. 91/94. Dispensada a audiência de custódia, ex vi do Provimento CSM 2545/2020, as prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-las necessárias à garantia da ordem pública (fls. 97/100). Às fls. 109/113 a defesa do inculcado Riquelme propugnou pela

revogação de prisão preventiva, o que fora repellido às fls. 126/127.

Às fls. 194/197, por estar em termos, a denúncia oferecida foi recebida, determinando-se a notificação dos acusados para fins de apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. Na mesma oportunidade, acolhendo-se a pretensão Ministerial, foi decretada a prisão preventiva de Samuel, indivíduo não preso em estado flagrancial com os demais acusados, bem como determinou-se sua citação editalícia.

Às fls. 302/303, na medida em que o réu Samuel, citado por edital, não compareceu em Juízo e tampouco constituiu defensor, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional para ele, nos termos do art. 366 do CPP. Todavia, determinou-se ainda o prosseguimento do feito em caráter de antecipação de provas.

Citados, os acusados apresentaram resposta a acusação (fls. 240/252 - Riquelme, 338/341- Gustavo e 359/362 - Samuel), por intermédio de defensores dativos. E, não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência por plataforma remota (fls. 369/372).

Na data aprazada, ressaltou-se que os réus seriam interrogados após a inquirição das testemunhas arroladas, seguindo a mesma sistemática do procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Na sequência, foram inquiridas as testemunhas Ricardo, Carlos, Lea e Wellington, arroladas em comum pelas partes, bem como foram interrogados os réus Riquelme e Gustavo.

Após, dada a instabilidade no sistema e-Saj, o Ministério Público requereu a designação de audiência presencial com fito de reinquirir as testemunhas Ricardo e Carlos, para confronto de provas (fls. 521/522). Na ocasião, pleiteou ainda a revogação da prisão preventiva dos acusados. A prisão cautelar foi revogada (fl. 523) e os alvarás de soltura foram expedidos (fls. 524/526 - Gustavo e 527/529 - Riquelme). Nova audiência designada (fl. 564) e depoimentos devidamente colhidos (fls. 589/590). Respeitante ao réu Samuel, foragido, para quem o processo seguiu em caráter de antecipação de provas, determinou-se a prisão do feito.

Encerrada a instrução (fl. 593), foram as partes intimadas para apresentação de memoriais. Em sede de alegações finais, a acusação, em linhas gerais, propugnou pela procedência parcial da denúncia (fls. 599/612), ao passo que a defesa requereu a absolvição dos réus, sob a égide da anêmia de provas (fls. 616/623).

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação dos acusados Gustavo Henrique Araújo Ferreira e Riquelme Lima Nogueira nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

PRELIMINARMENTE:

Da ausência de justa causa:

Ab initio, alega a Defesa do acusado Riquelme, em sua resposta escrita (fls. 240/252), inexistir justa causa a embasar a ação penal pública sub judice, em decorrência da inexistência de materialidade e autoria delitiva em relação ao increpado. Todavia, na medida em que já recebida a denúncia, a questão se encontra superada, devendo ser solucionada quando da apreciação do mérito, não ensejando, assim, o atalhamento da lide.

NO MÉRITO:

Em relação ao crime previsto no ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006:

Narra a denúncia que no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Senival Caviquioli, 72, apto 23, bloco I, Guapurá e na Rua Dezessete, 253, apto 22, Condomínio Andorinha, ambos localizados em Itanhaém, Gustavo Henrique Araújo Ferreira e Riquelme Lima Nogueira Beserra, agindo em unidade de desígnios entre si e com o adolescente Matheus Nascimento Rocha, mantinham em depósito, para fins de tráfico, 1860 porções de cocaína, 580 porções de maconha, 1 pedra de crack e 20 porções de skunk, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade dos fatos se enfeixa no auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), auto de constatação prévia de entorpecentes (fls. 22/23) e, principalmente, no laudo pericial toxicológico de fls. 277/280, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de 457,9g de cocaína e 1.389,2g de tetrahydrocannabinol. A autoria dos acusados, por seu turno, restou bem delineada por intermédio da prova testemunhal produzida.

O acusado Riquelme, quando de seu interrogatório realizado em solo policial (fl. 11), confessou estar traficando drogas na "Biqueira do Aeroporto", no Jardim Oásis. Esclareceu que o estupefaciente localizado na gaveta do armário da cozinha seria mercenciado. No mais, salientou ser, bem como o corréu Gustavo, de Ribeirão Preto, e que morava em Itanhaém a cerca de um mês.

Em Juízo (fl. 500), deu outro contexto. Disse ter alugado um apartamento com Gustavo, lá se encontrando com outras meninas. Em um determinado momento, policiais entraram no imóvel, todavia, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, foram todos conduzidos até um segundo apartamento, tripulando uma viatura da Disel. Pontuou que o adolescente não foi encontrado no segundo imóvel e sim no meio da rua. Salientou que alugaram o apartamento de um indivíduo chamado Patrick, tendo realizado o pagamento da quantia de R\$ 1.000,00. Tocante as meninas, disse que elas chegaram dois dias antes do fatídico dia. Por fim, disse que já foram apreendidos por tráfico de entorpecentes e receptação.

Já Gustavo, por ocasião de seu interrogatório na etapa indiciária (fl. 12), forneceu idêntica versão ao do réu Riquelme em solo policial. Sob o crivo do contraditório, por seu turno, da mesma sorte que o corréu, retratou-se, negando os fatos (fl. 499).

Todavia, quando confrontada a versão externada pelas acusadas com as demais provas produzidas, desfalecem ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratarem-se de um subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

O Policial Civil Carlos, em seu depoimento externado em solo indiciário (fls. 06/07) e em Juízo (fl. 496), relatou que, na data dos fatos, juntamente de seu companheiro Ricardo, dirigiu-se até a rua Senival Caviquioli, nº 72, apto. 23, bloco I, Guapura, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no processo 1500216.93.2022.8.26.0266, oriundo de investigação relacionada ao tráfico de drogas, junto a "Boca do Aeroporto", Jd. Oásis. Ao chegar ao lugar, bateu na porta do apartamento e informou a razão pela qual lá estava, encontrando-se, no imóvel, Gustavo e Riquelme. Após a realização de buscas, encontrou 17 eppendorffs de cocaína e 15 trouxinhas de maconha, devidamente acondicionados em uma gaveta do armário da cozinha. Também foi localizado nas buscas um contrato de locação residencial, cujo responsável seria Samuel Colmanetti Barbosa, bem como um pedaço de papel com endereço de um apartamento situado na rua 17, nº 253, apto. 22, Condomínio Andorinha. Dada a apreensão de entorpecentes no imóvel, resolveram se dirigir até o endereço descortinado, sendo que, ao chegarem e se identificarem como policiais, um indivíduo, posteriormente identificado como Matheus Nascimento Rocha, adolescente, tentou fechar a porta, todavia sem êxito. Em revista no apartamento,

encontraram 1843 eppendorffs de cocaína, 565 trouxas de maconha, 20 porções de skunk e 01 pedra de crack. No mais, salientou que os acusados e o adolescente informaram estar morando morando em Itanhaém acerca de um mês, vindo de Ribeirão Preto justamente para trabalhar na biqueira.

Ao ser novamente inquirido (fl. 591), acrescentou que as imagens exibidas referem-se, efetivamente, ao primeiro endereço, onde os acusados foram presos. Contudo, narrou que, quando da chegada ao condomínio, encontrou duas mulheres na parte comum do apartamento. Ao tomar ciência de que elas eram do apartamento a ser vistoriado, pediu para que estas permanecessem em silêncio, aguardassem e não utilizassem os aparelhos celulares. Explicou que o objetivo era evitar o anúncio da presença dos policiais. Em seguida, chegou uma terceira mulher, a qual recebeu a mesma orientação.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial civil Ricardo, em seu depoimento prestado em solo policial (fls. 08/09) e sob o crivo do contraditório (fls. 495 e 592).

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Outras provas ainda foram produzidas.

Sob o crivo do contraditório, Lorena (fl. 497), antiga namorada de Riquelme, também ouvida na qualidade de informante, esclareceu que vieram de Ribeirão Preto para Itanhaém a fim de permanecerem uns dias. A droga na realidade se encontrava em outro apartamento. Não soube esclarecer como os policiais descobriram o endereço do segundo apartamento. Disse conhecer Gustavo, por ser amigo de Riquelme, de Ribeirão Preto. Todos estavam no apartamento dormindo, quando da chegada dos policiais. Matheus, por seu turno, foi encontrado na rua, e não no segundo apartamento, após a apreensão do entorpecente.

Já Wellington (fl. 498), amigo de infância, disse ter ficado chocado quando soube da prisão de Riquelme. Salientou que seu amigo veio de Ribeirão Preto para Itanhaém única e exclusivamente para o fim de turismo. Soube que veio para cá acompanhado de alguns amigos.

Estas são as provas. Haure-se dos autos que o marco inicial das investigações foi a obtenção de informações, por parte dos policiais civis Carlos e Ricardo, acerca de novos responsáveis pelo controle e distribuição de drogas no Bairro Guapurá. Neste cenário, os agentes estatais passaram a realizar diligências nas redondezas, vindo a localizar o imóvel que estaria sendo utilizado para o armazenamento dos estupefacientes. Seguidamente, a Autoridade Policial, nos autos nº 1500216-93.2022.8.26.0266, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão (fls. 01/02 e 03/05).

Com a autorização judicial, a equipe investigativa rumou à Rua Senival Caviquioli, nº. 72, Apto. 23, Bloco I - Condomínio Turquesa, no bairro Guapurá, em Itanhaém. Ao chegarem no local, depararam-se com dois indivíduos, identificados como Guilherme e Riquelme, os quais franquearam a entrada dos policiais. No imóvel, lograram encontrar 17 eppendorfs de cocaína e 15 trouxinhas de maconha. Em seguida, os investigados confessaram que tinham vindo da cidade de Ribeirão Preto para trabalhar na biqueira do bairro (fls. 18/19 dos autos nº 1500216-93.2022).

Contudo, o que chamara atenção dos agentes foi um contrato de locação residencial, em nome de Samuel, acompanhado de um bilhete indicando outro endereço das proximidades, a saber: Rua 17, nº 253, Apto 22, Condomínio Anchieta, também no bairro Guapurá (vide fl. 30 - autos principais). Diante de fundadas suspeitas de ser outro ponto relacionado ao tráfico de drogas, os policiais resolveram dirigir-se à segunda moradia.

Neste aspecto, em sede de alegações (fls. 616/623), a Defesa arguiu haver contradição nos depoimentos dos policiais. Isto porque, inicialmente afirmaram que, no Condomínio Turquesa, localizaram apenas dois indivíduos, no entanto, saíram do local e rumaram ao Condomínio Anchieta acompanhados de outras pessoas.

De fato, percebe-se que a narrativa dada pelos agentes na etapa indiciária (fls. 06/07 - Carlos e 08/09 - Ricardo), colide com a mídia acostada pela Nobre Defensora à fl. 478. Isto porque, a partir dela é possível visualizar Riquelme e Gustavo saindo do endereço alvo de cumprimento dos mandados na companhia de outras 03 mulheres.

Contudo, ao serem novamente inquiridos (fls. 589/590), os policiais, a uma só voz, afirmaram que, quando do cumprimento do mandado, na parte comum do condomínio, encontraram, inicialmente, duas mulheres, átimo em que determinaram a não utilização de seus aparelhos celulares por um determinado período - com fito de evitar eventual aviso aos inculpadados da iminente diligência policial. Estas então ficaram sentadas na escada do prédio. Porém, posteriormente, enquanto adentravam o apartamento, apareceu uma terceira mulher e, juntamente com as outras duas que tinham ficado aguardando sentadas, passou a falar que também residiam no imóvel. Entretanto, haja vista que elas não tinham sido o foco das investigações e os suspeitos já tinham confessado a traficância, não as qualificaram como partícipes da teia delitiva (vide fls. 591 - Carlos e 592 - Ricardo).

Pois bem, ao chegarem no segundo endereço - Condomínio Anchieta -, a equipe foi recepcionada pelo adolescente Matheus que, ao perceber que se tratavam de policiais, tentou fechar a porta da residência. Ainda sim, os investigadores conseguiram ingressar no imóvel, momento em que depararam-se com outros 1.843 eppendorfs de cocaína, 565 trouxinhas de maconha, 20 porções de skunk e 01 pedra de crack destinadas ao abastecimento do mesmo ponto de venda.

Dito isso, diferentemente do que pretendem fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico ofertada aos réus. O contexto formado inculca neste Juízo inexorável certeza de que Matheus, Gustavo e Riquelme efetivamente eram os titulares dos entorpecentes. E mais, a quantidade de droga encontrada - 457,9g de Cocaína e 1.389,2g de Tetrahidrocannabinol - e as circunstâncias que envolvem o caso (a forma como estavam acondicionados os entorpecentes) transparecem a finalidade comercial própria do tipo penal.

De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar desconhecidos da prática de um delito unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros. A uma, se inverídicas fossem tais informações, não haveria razão para os agentes estatais se dirigirem aos endereços onde se encontravam Gustavo e Riquelme e Matheus, local onde foi encontrada a expressiva quantidade de entorpecentes. A duas, a localização de mais

entorpecentes no segundo endereço tem o condão de, mais uma vez, confirmar a idoneidade das diligências policiais e a responsabilidade criminal dos acusados na narcotraficância.

Por fim, a título de cautela, cumpre aqui ressaltar que a coautoria é patente diante da Teoria Monista adotada pelo Código Penal vigente, tendo seu conceito amplitude inquestionável. Todos que participam, de qualquer modo, da ação delituosa, são autores, independentemente do seu grau de culpa. Significa dizer que a coautoria não depende de prática de atos de execução pelo coautor, sendo suficiente a simples presença física do coautor, em atitude de solidariedade e possibilidade de auxiliar os outros agentes.

“O Código Penal adotou, como regra, a teoria unitária, também conhecida como monista, determinando que todos, coautores e partícipes, respondam por um único delito. Nesse passo, seu art. 29, caput, dispõe que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, todos aqueles que, na qualidade de coautores ou partícipes, deram a sua contribuição para o resultado típico devem por ele responder, vale dizer, todas as condutas amoldam-se ao mesmo tipo legal (...)” - (CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal volume 1, 15ª edição, 2010, p. 366.)

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

“o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Assentadas, pois, a materialidade dos fatos e a autoria do acusado em relação ao crime de tráfico, passo à perquirição acerca da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI da Lei 11.343/2006.

Dispõe o art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas que as penas prevista nos arts. 33 a 37 da mesma lei serão aumentadas de um sexto a dois terços se a sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer outro motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. A causa de aumento de pena em questão, em sua exegese teleológica, objetiva punir mais severamente aqueles que praticam o tráfico de entorpecentes, envolvendo ou atingindo crianças ou adolescentes.

Em outras palavras, basta o simples envolvimento ou atingimento, sendo irrelevante aferir quem é a pessoa do menor. A intenção do legislador não foi criar um preceito protetivo para os menores, até porque este já existe e está tipificado no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

Deste modo, para o reconhecimento desta causa especial de aumento de pena, pouco importa que o menor seja vocacionado à delinquência, que seja toxicômano ou que se tenha notícia de que ele já praticou atos infracionais para sustentar seu vício.

Isso porque, vale repisar, a interpretação que se deve atribuir ao inciso VI, do art. 40, da Lei Antidrogas, é a de que não se trata ele de uma norma protetiva, e sim de uma norma de majoração de reprimenda, servindo ainda de instrumento de

coerção para dificultar a engenharia do tráfico, que utiliza crianças e adolescentes, viciadas ou não, a servirem de obreiros para a prática criminosa.

No caso em apreço, as provas produzidas indicam, com inexorável certeza, que os acusados estavam realizando a venda de entorpecentes com o auxílio do adolescente Matheus Nascimento Rocha. Veja-se que, conforme relato prestado pelos policiais, o juvenil estava, quando da abordagem policial, no segundo apartamento armazenando os entorpecentes. Não bastasse, ao notar a presença dos agentes, tentou fechar a porta para que estes não adentrassem o imóvel, contudo, não obteve êxito e a droga espúria foi localizada.

Em resumo, encontram-se, pois, os acusados incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao crime de Associação para o Tráfico:

De antemão, sobre o ônus da prova, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão a conclusão alcançada nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional.

E, para tanto, soa adequado rememorar, com esquete na lição de Aury Lopes Júnior, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, “entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações” (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, pag. 45).

Ocorre que, no processo penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, “não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência” (ob. cit.) (Grifei).

Vale dizer, em âmbito penal, considerando a relevância e indisponibilidade da natureza da matéria discutida – liberdade do indivíduo – não existe uma distribuição na produção da prova, pois esta se encontra exclusivamente nas mãos do Ministério Público.

Ainda segundo o escólio do referido professor, “o que sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa.” (Grifo no original) (ob. cit.).

Em outras palavras, “carga é um conceito vinculado à noção de unilateralidade, logo, não passível de distribuição, mas sim de atribuição. No processo penal, a atribuição da carga probatória está nas mãos do acusador, não havendo carga para a defesa e tampouco possibilidade de o juiz auxiliar o MP a liberar-se dela (recusa ao ativismo judicial)” (ob. cit.).

Pode-se falar, portanto, que a defesa assume riscos pela perda de uma chance:

“Assim, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa chance, assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance, logo, assunção do risco de uma sentença desfavorável. Exemplo típico é o exercício do direito de silêncio, calcado no nemo tenetur se detegere. Não gera um prejuízo processual, pois não existe uma carga. Contudo, potencializa o risco de

uma sentença condenatória. Isso é inegável”(ob. cit.) (Grifei).

A conclusão a que se alcança, portanto, é a de que “não há uma carga para a defesa exatamente porque não se lhe atribui um prejuízo imediato e tampouco possui ela um dever de liberação. A questão desloca-se para a dimensão da assunção do risco pela perda de uma chance de obter a captura psíquica do juiz. O réu que cala assume o risco decorrente da perda da chance de obter o convencimento do juiz da veracidade” (ob. cit.) (Grifei).

Em suma, a necessidade de produção da prova para amparar a condenação dos réus repousa unicamente nas mãos da acusação, não havendo que se falar em distribuição de cargas processuais.

Assentadas essas premissas, passo ao crime perquirido.

Narra a denúncia que, durante um pouco mais de 01 mês, período que se encerrou no dia 04 de fevereiro de 2022, neste município de Itanhaém, Gustavo e Riquelme, associaram-se entre si e com o adolescente Matheus Nascimento Rocha, de forma estável, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Aos acusados imputa-se o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, tal como asseverado no preâmbulo da presente sentença, a saber:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.”

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei n. 6.368/76) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa (Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1. ed., 2006, p. 785).

E mais, “consoante jurisprudência pacificada do STF e do STJ, o art. 35 configura-se pela efetiva associação, com idéia de estabilidade e permanência. Deve haver 'animus' associativo e não mero concurso eventual de pessoas. Assim, o crime de associação não depende da apreensão da droga; sua comprovação pode ser feita nos mesmos moldes da quadrilha (art. 288 do Código Penal). Trata-se de crime formal, que se consuma com a demonstração do desígnio de convergência de vontades para traficar droga.” (Gilberto Thums e Vilmar Pacheco in Nova Lei de Drogas - Crimes, Investigação e Processo, ed. Verbo Jurídico, 2007, págs. 92/93).

Exige-se, portanto, a demonstração de vínculo estável entre os agentes, voltado à prática do tráfico de drogas.

No presente caso, todavia, as provas carreadas são insuficientes a uma condenação. De todo oportuno pontuar que, embora tenham apreendido entorpecentes na residência dos réus (457,9g de Cocaína e 1.389,2g de Tetrahydrocannabinol), com a máxima vênia ao órgão acusador, não compartilho do entendimento de que a hipótese dos autos não deixa dúvidas sobre o envolvimento dos incriminados no comércio de drogas.

Isto porque no decurso do feito, além dos depoimentos dos policiais militares, nenhuma outra prova a este respeito foi produzida a fim de comprovar o dolo de se

associar com estabilidade e permanência. É claro que não se está a dizer que faltaram os policiais com a verdade frente a este Juízo. Todavia, a conclusão a que alcanço, é a de que a prova produzida pela acusação se vislumbra demasiadamente frágil.

O Direito Penal, vale lembrar não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição da parte acusada é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), observava:

“Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”.

Acerca dessa matéria:

“O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP).

“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial provimento Unânime” (RJTJESGS 17/136).

Assim, a absolvição dos acusados em relação ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe, com esteio no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA:

Em relação ao acusado GUSTAVO:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer:

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado” (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas gravosas tendo em vista a quantidade dos entorpecentes apreendidos (457,9g de Cocaína e 1.389,2g de

Tetrahydrocannabinol) e as circunstâncias que envolveram o fato. Vale a consideração, também, que o montante de entorpecente apreendido se traduz no mercado ilícito em expressiva cifra, pelo que, fica exasperada a pena em 1/6. Nesse sentido:

"(...) na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa" (STJ, Rel. José Arnaldo da Fonseca, HC 18940/RJ).

As consequências devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Ausentes quaisquer agravantes. Presentes a atenuante de menoridade relativa (contava com 20 anos a época dos fatos - vide fls. 15/16), ex vi no inc. I do art. 65 do Código Penal, atenuo a pena em seu mínimo.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente no tráfico de drogas), majoro a pena em 1/6 (um sexto). Ausentes quaisquer de diminuição, inclusive a prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Considerando a expressiva quantia de entorpecente apreendida, deixo de operar a diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. É que tais circunstâncias revelam séria incursão da parte acusada na criminalidade, inculcando neste Juízo seja ele dedicado à atividades criminosas.

Não é preciso dizer muito para se compreender que a aquisição de tamanha quantidade de entorpecente não se dá com qualquer indivíduo, notadamente com o pequeno traficante. A perda da droga enseja inegável prejuízo, razão pela qual, no mundo do crime, exige-se responsabilidade de quem a transporta. Assim, se logrou a parte acusada assim agir, é porque está inserida na senda delitativa, não fazendo jus, portanto, à redução reclamada pela defesa. A este respeito, observo que:

"o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

E nem se argumente por bis in idem em relação à quantidade da droga observada na exasperação da base, porquanto, nesta etapa, tal circunstância não é tomada como critério próprio para obstar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, mas, sim, como elemento de convicção que se sintetiza a outros extraídos dos autos e sustentam, afirmativamente, o entendimento de dedicação à atividade criminosa, este, sim, por lei, critério próprio impeditivo do privilégio.

Acerca do entendimento, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"2. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a

atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. (...) 5. Não configura bis in idem caso, além da quantidade de drogas, haja outros elementos concretos nos autos, suficientes o bastante - tais como apetrechos destinados à traficância, anotações sobre contabilidade do tráfico, munições, armas de fogo, processos em andamento etc. -, que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. (...)" (HC 373.523/SP; Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz; Sexta Turma; julgado em 14/08/2018; DJe 21/08/2018)

E ainda:

"EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO QUE EXCLUIU A INCIDÊNCIA DA REDUTORA DISPOSTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. Na hipótese retratada nos autos, verificou-se que o embargante utilizava sua residência como um depósito de grande quantidade de maconha; embora o réu tenha referido que trabalhava em uma lavagem dentro de sua casa, ao realizarem campanhas naquele endereço, os agentes públicos viram pouca movimentação de clientes lavando seus veículos no local, sendo referido nas informações constantes no incidente do mandado de busca e apreensão que havia movimentação típica de venda de drogas na residência. Ademais, o depósito de 9.430 kg de maconha demonstra relação estreita com traficantes maiores e conhecimento suficiente da logística afeta ao tráfico, possibilitando concluir-se que a prática do injusto penal era contínua e profissional. Inviável, portanto, o reconhecimento da redutora, pois não cumpridos as exigências que a legislação prevê para a aplicação da referida causa de diminuição. DESACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70079233383; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba; Julgado em 05/04/2019)." (TJ-RS - EI: 70079233383 RS; Relator: Rosaura Marques Borba; Data de Julgamento: 05/04/2019; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019)

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei n. 11.343/06.

Considerando que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

"É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." (ARE 935.967 AgR; Rel. Min. Edson Fachin; Primeira Turma; J.:15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos

concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista a quantidade e diversidade de droga encontrada, alinhada à sua nocividade (cocaína), ex vi do art. 33, §2º, 'b', e §3º do mesmo preceito.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do artigo 44 do Código Penal.

Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos arts. 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

“remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.” E isso por se entender que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material”.

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

Todavia, mesmo que assentadas tais premissas, as circunstâncias do caso indicam não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão condicional de sua execução. Como já positivado, além da grande quantidade de entorpecente encontrado, sua toxidade é latente (cocaína), o que revela a nocividade em seu comportamento, não compatível com a branda possibilidade de concessão dos benefícios referidos (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Em relação ao acusado RIQUELME:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo

condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer:

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas gravosas tendo em vista a quantidade dos entorpecentes apreendidos (457,9g de Cocaína e 1.389,2g de Tetrahydrocannabinol) e as circunstâncias que envolveram o fato. Vale a consideração, também, que o montante de entorpecente apreendido se traduz no mercado ilícito em expressiva cifra, pelo que, fica exasperada a pena em 1/6.

Nesse sentido:

"(...) na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa" (STJ, Rel. José Arnaldo da Fonseca, HC 18940/RJ).

As consequências devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Ausentes quaisquer agravantes. Ausentes quaisquer agravantes. Presentes a atenuante de menoridade relativa (contava com 19 anos a época dos fatos - vide fl. 15), ex vi no inc. I do art. 65 do Código Penal, atenuo a pena em seu mínimo.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente no tráfico de drogas), majoro a pena em 1/6 (um sexto). Ausentes quaisquer de diminuição, inclusive a prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Considerando a expressiva quantia de entorpecente apreendida, deixo de operar a diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. É que tais circunstâncias revelam séria incursão da parte acusada na criminalidade, inculcando neste Juízo seja ele dedicado à atividades criminosas.

Não é preciso dizer muito para se compreender que a aquisição de tamanha quantidade de entorpecente não se dá com qualquer indivíduo, notadamente com o pequeno traficante. A perda da droga enseja inegável prejuízo, razão pela qual, no mundo do crime, exige-se responsabilidade de quem a transporta. Assim, se logrou a parte acusada assim agir, é porque está inserida na senda delitativa, não fazendo jus, portanto, à redução reclamada pela defesa. A este respeito, observo que:

"o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância

sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas" (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

E nem se argumente por bis in idem em relação à quantidade da droga observada na exasperação da base, porquanto, nesta etapa, tal circunstância não é tomada como critério próprio para obstar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, mas, sim, como elemento de convicção que se sintetiza a outros extraídos dos autos e sustentam, afirmativamente, o entendimento de dedicação à atividade criminosa, este, sim, por lei, critério próprio impeditivo do privilégio.

Acerca do entendimento, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"2. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. (...) 5. Não configura bis in idem caso, além da quantidade de drogas, haja outros elementos concretos nos autos, suficientes o bastante - tais como apetrechos destinados à traficância, anotações sobre contabilidade do tráfico, munições, armas de fogo, processos em